PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012254-26.2022.8.21.0021/RS

AUTOR: FERNANDA NICOLINI PATUSSI (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
ADVOGADO(A): LAURIANE SABO MULLER CARLINI (OAB RS085555)

REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR: EDUARDO GRIGOLLO PATUSSI (PAIS)

RÉU: UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
ADVOGADO(A): ALBANO BUSATO TEIXEIRA (OAB RS077782)

SENTENÇA

Vistos, etc.

FERNANDA NICOLINI PATUSSI, menor, absolutamente incapaz, representada por **EDUARDO GRIGOLLO PATUSSI**, todos qualificados na inicial, ajuizou a presente *ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência* em desfavor de **UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, igualmente qualificada. Narrou ser dependente do plano de saúde do demandado e, atualmente com 07 anos de idade, foi diagnosticada há três anos com dermatite atópica na forma grave (CID - 10: L20.9), doença que acomete principalmente crianças. Asseriu que a patologia causa inúmeros transtornos em razão dos sintomas que apresenta, tais como erupções cutâneas pruriginosas, feridas, alterações no sono, dentre outros, comprometendo sua qualidade de vida. Relatou que, desde então, se submete a diversos tratamentos tópicos que se mostraram inexitosos, mencionando haver contraindicação pela literatura médica do uso de medicamentos via oral, como corticosteróides, em razão do efeito rebote, propiciando uma melhora momentânea, mas, posteriormente, um agravamento do quadro associado a outros efeitos colaterais. Nos últimos meses, esgotadas as tentativas pelos métodos tradicionais existentes no mercado, sua médica assistente indicou a utilização do medicamente DUPILUMABE (anticorpo monoclonal humano), o qual já teve sua eficácia cientificamente comprovada, mostrando-se determinante na remissão de sintomas relacionados à doença. Asseriu que o referido tratamento, aprovado pelo FDA e registrado na ANVISA (para esta finalidade) sob o nº183260335, consiste no bloqueio da resposta inflamatória, responsável pela deflagração dos sintomas da doença, inibindo-os. Asseriu que seu genitor, titular do plano de saúde há 10 anos, solicitou o fornecimento do medicamento administrativamente, porém, houve negativa por parte da ré pelo fato de a indicação clínica não se enquadrar na diretriz da ANS. Sustentou que tal negativa não merece prosperar, porque o medicamento foi incluído no respectivo rol por meio da Resolução Normativa n° 513 de 31/03/2022, e, em vista disso, deve ser fornecida pelo plano de saúde. Discorreu sobre os fundamentos jurídicos, destacando o direito fundamental à saúde, com prioridade reconhecida pelo ECA, a aplicabilidade do CDC e abusividade da negativa administrativa da ré. Requereu a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que a ré forneça o medicamento DUPILUMABE 300mg, na quantidade indicada no atestado médico, sob pena de multa diária ou sequestro de valores para aquisição do medicamento. Postulou a procedência do feito, confirmando-se a tutela provisória de urgência requerida. Instruiu a inicial com documentos (evento 1, DOC1). Recolheu as custas (evento 5, DOC2).

Recebida a inicial, deferida a tutela provisória de urgência, determinando que a ré fornecesse o medicamento no prazo de 10 dias, sob pena de sequestro de valores para compra do medicamento, dispensada a designação de audiência de conciliação e determinada a citação da parte ré para contestar (evento 8, DOC1).

Citada (evento 14, DOC1), a parte ré apresentou contestação evento 17, DOC1. Argumentou que a RN n° 465/2021 da ANS incluiu o tratamento de terapia imunobiológica nas coberturas obrigatórias previstas pelo Rol da ANS, mas, estipulou diretrizes para a sua utilização, sendo a DUT nº 65. A RN 513 acrescentou como indicação casos de Tratamento de pacientes com câncer de próstata não metastático resistente à castração, o que não é o caso dos autos, de modo que não há razão em dizer que a referida norma tornou o medicamento obrigatório para o caso dos autos. Sustentou que a patologia da autora não compreende as previstas de cobertura obrigatória, sendo assim, não é obrigatório que a ré custeie o tratamento. Defendeu a licitude da negativa apresentada, consistindo exercício regular de direito. Discorreu sobre as cláusulas contratuais que excluem a cobertura para tais casos. Postulou a improcedência do feito. Acostou documentos.

A parte ré interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (processo 5121765-71.2022.8.21.7000/TJRS, evento 27, ACOR1).

Houve réplica (evento 21, DOC1).

Intimadas as partes acerca do interesse na produção de outras provas (evento 22, DOC1).

A parte ré requereu a juntada do contrato de plano de saúde firmado pelo titular do plano (evento 26, DOC1).

Diante do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, a parte autora requereu a intimação da parte ré, pessoalmente, por Oficial de Justiça, acerca da decisão para fins de imediata disponibilização do medicamento, que havia sido interrompida (evento 28, DOC1).

Aportou aos autos carta de ordem oriunda do e. TJRS, a fim de dar cumprimento à decisão que restabeleceu a tutela provisória de urgência (evento 39, DOC2).

Determinada a expedição de mandado para intimação da ré, com urgência (evento 40, DOC1), cumprido no evento 45, DOC1.

Comprovado o cumprimento da decisão por parte da ré (evento 47, DOC2).

Intimado o Ministério Público para apresentar parecer de mérito (evento 56, DOC1).

O Ministério Público opinou pela procedência do feito (evento 59, DOC1).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo à fundamentação.

O feito foi regularmente instruído, não havendo nulidades. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. A relação consumerista já foi reconhecida, tendo sido invertido o ônus probatório. Passo, de imediato, ao exame do mérito, diante da ausência de preliminares ou questões pendentes de apreciação.

MÉRITO

DA APLICABILIDADE DO CDC

Inicialmente, reforço que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao presente caso, enquadrando-se, autora e ré, nos exatos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços preconizados pelos arts. 2° e 3°. Inclusive, este é o entendimento sumulado no verbete n° 608 do STJ:

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)".*

Ademais, trata-se de típico contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC, com cláusulas pré-estabelecidas e sem margem para discussão por parte do consumidor.

DO PLANO DE SAÚDE

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora insurge-se contra a negativa de fornecimento da ré ao tratamento médico a base do medicamento DUPILUMABE 300mg. Em suma, a ré argumenta que a negativa é lícita, porquanto o medicamento não possui respaldo para utilização na forma como pretendido pela autora, pois fora das diretrizes estabelecidas pelas diretrizes da ANS.

De plano, enfatizo que a parte autora é segurada, como dependente, a doença coberta e o tratamento igualmente. Resta a questão da possibilidade de concessão do tratamento/medicamento e da taxatividade ou exemplificatividade do rol de procedimentos e tratamentos da ANS. Havia profunda divergência jurisprudencial no âmbito do STJ entre a Terceira e Quarta Turma[1]. Entretanto, recentemente, a Segunda Seção do Sodalício firmou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, com algumas exceções (mitigado, portanto). Eis a ementa do julgado de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, cuja publicação ocorreu em 03/08/2022:

> *EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.*
>
> *1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.*
>
> *2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.*
>
> *3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3º, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar.*

4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população.

5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual.

6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol.

7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar.

8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada.

9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais.

11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.

13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado.

14. Embargos de divergência a que se nega provimento.

(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Curial destacar que não houve o trânsito em julgado da decisão, estando pendente de julgamento agravo em recurso extraordinário[2].

Porém, inobstante o cenário acima descrito, o Congresso Nacional sancionou a Lei n° 14.454/22, em 21/09/22, com vigência a partir da publicação, que, especialmente, alterou o disposto no art. 10 da Lei n° 9.656/98, com o seguinte teor:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *(...)*
>
> ***§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> ***§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> ***I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> ***II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) - grifei.***

In casu, portanto, tenho que ocorreu o fenômeno da superação (ou reversão) da jurisprudência da Corte Superior, não sendo caso de aplicação da tese firmada pelo STJ, cuja ementa alhures transcrevi, nos termos do art. 489, §1°, inciso VI do CPC.

Como assentou o Min. Luiz Fux, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.105/DF[3], abordando a tese dos diálogos institucionais e os limites à reação legislativa às decisões do Supremo Tribunal Federal *"essa práxis dialógica, além de não ser incomum na realidade interinstitucional brasileira, afigura-se perfeitamente legítima — e, por vezes, desejável —, estimulando prodigioso ativismo congressual, desde que, é claro, observados os balizamentos constitucionais"* de modo que, *"ao legislador é franqueada a capacidade de interpretação da Constituição, a despeito de decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo".*

Firmada tal premissa, à luz da essencialidade do bem objeto do contrato - tratamento da saúde - e rendendo-me à mudança legislativa, estou por acolher o pedido de fornecimento do medicamento/tratamento vindicado pela parte autora, reconhecendo a ilicitude da negativa prestada pela ré.

Urge destacar a função social específica dos contratos (art. 421 do CC), especialmente quando o objeto são direitos sensíveis, como no caso de planos privados de assistência à saúde, por meio do qual o consumidor, de um lado, assume o compromisso de pagar as prestações pecuniária periódicas dos serviços ofertados pela operadora que, por seu turno, tem o dever de prestar o tratamento médico abrangido pelas coberturas definidas contratualmente. Ao se interpretar estes contratos, é preciso atender à sua teleologia e à boa-fé objetiva, pois os consumidores são levados a crer possuírem certas coberturas, invariavelmente negadas mais adiante, o que não realiza nem a boa-fé objetiva nem a função social destes contratos.

Com efeito, o vínculo contratual entre as partes é incontroverso, assim como é fato a existência de cobertura para a patologia e tratamento de que necessita a autora, na linha do que dispõe o contrato juntado no evento 26, DOC3.

A controvérsia dos autos reside na obrigatoriedade do fornecimento de medicamento fora da lista de diretrizes elaboradas pela ANS, conforme contesta a parte ré, e consoante negativa colacionada pelo autor no evento 1, DOC10, da qual se depreende que o pedido foi negado em razão de que a indicação clínica para solicitação não se enquadra na diretriz de utilização da ANS, conforme determina a Resolução n° 465 da ANS, Anexo II.

DA NEGATIVA DE COBERTURA

Conforme o atestado colacionado pela autora no evento 1, DOC8, houve diagnóstico de quadro dermatite atópica (CID-10: L20.9), recomendando-se a utilização do medicamente Dupilumabe 300mg.

A obrigação de prestar a saúde decorre da contratação sinalagmática feita e o próprio princípio da função social do contrato, alhures ressaltado, impõe a interpretação da vontade das partes no sentido de proteger a saúde e privilegiar a melhor prestação possível. De mais a mais, dado que o feito é analisado sob a ótica do direito do consumidor, é de se frisar que a cláusula contratual que impossibilite o tratamento vindicado pela autora, a par de existir cobertura no plano de saúde, é nula de pleno direito, por consistir em abuso tendente a desequilibrar a relação contratual entre consumidor (autora) e prestadora de serviços (ré). Nessa linha, dispõe o artigo 51, incisos I e IV e §1° do Código de Defesa do Consumidor, *in verbis*:

> ***Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:***

*I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou **impliquem renúncia ou disposição de direitos.** Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;*

[...]

*IV - **estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;***

[...]

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

*II - **restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;***

*III - **se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. (grifei)***

Além disso, é de se registrar que no Microssistema estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, impositiva a interpretação de cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável, concretizando o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, precedente recente do e.TJRS, já amoldando seu entendimento ao disposto na Lei n° 14.454/22:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. ELETROCONVULSOTERAPIA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS QUE, EM REGRA, É TAXATIVO. LEI Nº 14.454/22. CONFIGURADA EXCEÇÃO À REGRA. DEVER DE COBERTURA CONFIGURADO. MULTA ASTREINTE. LIMITAÇÃO AOS DIAS DE DESCUMPRIMENTO. 1) Considerando que o referido Rol da autarquia regulamentadora não visa privilegiar nenhuma das partes, mas apenas harmonizar a relação contratual com substrato em diretrizes técnicas relevantes, adota-se o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui, em regra, natureza taxativa e deve ser observado com vistas a garantir o equilíbrio contratual, salvo enquadramento de situação excepcional, nos termos da Lei nº 14.454/2022. 2) Em que pese o procedimento postulado - eletroconvulsoterapia -, não conste no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS qualquer previsão, em consulta ao Sistema E-NATJUS - ferramenta lançada para auxiliar na solução das controvérsias, como apoio ao judiciário, pelo CNJ e o Ministério da Saúde -, foi possível aferir, na Nota Técnica nº 139431, de 02/06/2023, a eficácia da Eletroconvulsoterapia (ECT) para tratar Transtorno afetivo bipolar, considerando "quadros refratários de depressão. Paciente já com vários esquemas terapêuticos e com ideação suicida." 3) **Caso dos autos em que a demandante já tentou tratamento medicamentoso sem sucesso, de forma que se afigura adequada a prescrição médica para o tratamento sub judice, cabendo ao plano de saúde a cobertura da eletroconvulsoterapia, vez que, embora não constante no Rol da ANS, restou demonstrada situação excepcional, nos termos da Lei nº 14.454/2022.** 4) A prova dos autos demonstrou que a requerida foi intimada da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em 14/11/2022, de forma que tinha até o dia 24/11/2022 para cumprir a determinação, o que não ocorreu, vez que a operadora do plano de saúde apenas autorizou a liberação das guias do procedimento em 06/12/2022, ou seja, 12 dias após expirar o prazo para cumprimento da medida. 5) Em que pese a parte ré não tenha cumprido a decisão judicial dentro do prazo previsto, não se vislumbra substrato para a condenação no montante de R$ 90.000,00 (equivalente a 60 dias multa), porquanto a multa fora fixada em R$ 1.500,00 por dia de descumprimento, o que, considerando os 12 dias de inércia, alcança a cifra de R$ 18.000,00. 6) Descabido o pedido de redução do valor arbitrado por dia de descumprimento a título de astreinte, em razão da preclusão da decisão que a fixou. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50457239620228210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 28-09-2023) - grifei.*

Ademais, não se pode olvidar que o autor é criança em tenra idade, afigurando-se necessária a observância do princípio da proteção integral, consoante exegese do art. 3°, parágrafo único do ECA[4].

Por outro lado, a parte autora juntou diversos documentos científicos recomendando a utilização do medicamento em questão em diversas situações (evento 37, DOC1), o que atende ao disposto no §13 do art. 10, da Lei n° 9.656/98. Dentre eles, para além da da Nota Técnica n° 86400, de 25/07/2022, extraída da ferramente E-NATJUS do CNJ e Ministério da Saúde, mencionada pela eminente Desembargadora Eliziana da Silveira Peres em seu voto divergente, a autora acostou a Nota Técnica n° 87992, de 02/08/2022 (evento 37, DOC4), contendo parecer favorável para utilização em paciente do sexo feminino de 07 anos de idade, ou seja, mesma faixa etária da autora.

Diante disso, reconhecendo a ilicitude da negativa ao fornecimento do tratamento ao autora com o medicamento DUPILUMABE, o feito merece juízo de procedência para, confirmando a tutela de urgência concedida, determinar à demandada o fornecimento do medicamento/tratamento indicado pela profissional médica assistente do autor, pelo tempo e quantidade em que for necessário.

Gize-se que, havendo superveniente alteração no medicamento prescrito e assemelhando-se a situação dos autos, a conclusão exposta neste *decisium* não difere, devendo a parte ré observar o receituário da médica assistente da parte autora - observância da cláusula geral *rebus sic stantibus*.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmando a tutela provisória de urgência concedida no evento 8, DOC1 e com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **FERNANDA NICOLINI PATUSSI** em desfavor de **UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, para o efeito de condenar a parte ré o medicamento/tratamento indicado pela profissional médica assistente da autora, pelo tempo e quantidade em que for necessário.

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento da Taxa Única e despesas processuais, além de honorários advocatícios à Procuradora da parte autora, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85 do CPC, considerando a natureza da causa, tempo de tramitação e trabalho desenvolvido.

Interposto recurso de apelação por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.

Publique-se. Registrado e intimado eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA JUNIOR, Juiz de Direito**, em 19/4/2024, às 15:53:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10058874658v12** e o código CRC **42defc1d**.

---

1. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA (HOME CARE). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO NCPC. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. ROL ANS. TAXATIVO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia em conformidade com a atual orientação desta Corte, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que da natureza do negócio firmado.3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil/2015 (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.661.484/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 23/2/2018). Além disso, qualquer outra análise acerca do caráter procrastinatório dos embargos de declaração, que ocasionou a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do NCPC, seria imprescindível a análise fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, por força do óbice da Súmula nº 7 desta Corte.4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, em recentíssimos julgados, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1924587/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) ↩

2. https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=202001916776. Acesso em 07/10/23. ↩

3. ADI 5105, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 15-03-2016 PUBLIC 16-03-2016. ↩

4. Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) ↩